



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/273/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין דגנית
קציר-ברין

התובעת:

שאשא נאוה ת.ז. 4590064

ע"י ב"כ עו"ד ערן קנר
שדי שאול המלך 35 בית אמריקה – תל-אביב
טל: 03-6969701 פקס: 03-6969705

נ ג ד

הנתבעת:

ממן פנינה ת.ז. 5064806

ע"י ב"כ עו"ד אריאל מירון
מר'י המרד 25, ת.ד. 50236 תל-אביב 6150102
טל: 03-6378000 פקס: 03-7617400

פסק – דין

1. עניינה של תביעה זו היא עתירת התובעת לסילוק ידה של הנתבעת מחצר הבית המשותף והשבת מצב החצר לקדמותו לרבות הסרת מיטלטלין וגדרות שהונחו ברחבי חצר הבית המשותף.
כן עתרה התובעת בתביעתה לדמי שימוש ראויים בגין השימוש דלעיל.

א. כללי

2. התובעת היא החוכרת הרשומה של דירה הידועה כחלקת משנה 4 הממוקמת בקומה הראשונה בבית המשותף המצוי ברחוב פרופ' שור 8 בחולון (להלן: "**הבית המשותף**" או "**הבית**"); הבית המשותף ידוע גם כחלקה 84 בגוש 6018.
הבית המשותף מכיל סה"כ 4 דירות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/273/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. הנתבעת היא החוכרת הרשומה של דירה אחרת בבית הידועה כחלקת משנה 2, דירתה הנ"ל ממוקמת בקומת הקרקע של הבית המשותף תחת דירת התובעת (להלן: "הדירה").

את דירות הבית מקיפה חצר המהווה רכוש משותף.

4. על הבית חל התקנון המצוי אשר בתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט 1969.

5. במסגרת רישום הבית המשותף לא הוצמדו שטחים למי מדירות הבית.

ב. תמצית טענות התובעת

6. הנתבעת תפסה חזקה ייחודית ברכוש המשותף. ובכלל זאת הקימה חניה המשמשת את דירתה בלבד, הקימה בחצר הבית גינה פרטית שבה הותקנה בריכה והוצבו שולחנות וכיסאות וכן גודר חלק מהחצר לשימושה הייחודי.

7. הנתבעת השכירה את דירתה לצד ג' המסיגים את גבול הרכוש המשותף ועושים בחצר הבית שימוש ייחודי ללא הסכמת התובעת.

8. הנתבעת והשוכרים מטעמה מונעים מהתובעת כניסה לחצר ושימוש בה וזאת, על אף שעל פי הדין, מדובר ברכוש משותף.

9. בסיכומיה, זנחה התובעת את תביעתה הכספית בנוגע לדמי השימוש הראויים בגין תפיסת החזקה ברכוש המשותף, דרישתה מתמצית בסילוק ידה של הנתבעת ומטלטליה מחצרות הבית, הסרת הגדרות ושער החניה ואיסור שימוש ייחודי ברכוש המשותף.

ג. תמצית טענות הנתבעת

10. בין בעלי הדירות קיימת הסכמה בהתנהגות הנוהגת מזה למעלה מ-30 שנה לפיה דיירי קומת הקרקע זכאים לעשות שימוש בחצר הבית ולפיקח הם גם האחראים לתחזוקתה. מנגד, לבעלי הדירות בקומה הראשונה קיימת זכות שימוש ייחודית בשטח הגג המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/273/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אופי שימוש זה ברכוש המשותף מקובל בבתים מסוג זה ובפרט בבתים הממוקמים
בסמיכות לבית נשוא התביעה.

11. הנתבעת עושה שימוש בחצר הבית במשך תקופה העולה על 30 שנה בהסכמת כלל
בעלי הדירות (לרבות התובעת) והתובעת מעולם לא הלינה על כך.

12. התובעת מעולם לא דאגה ולא השתתפה בעלויות לתחזוקת החצר.

13. קיימת הפרדה פיזית בין קומת הקרקע לבין הקומה הראשונה כך שהכניסה לדירת
התובעת היא דרך גרם מדרגות העובר במרכז הבית המשותף ללא כל גישה לחצר
הבית ואילו הכניסה לדירתה של הנתבעת היא אך ורק דרך החצר.

14. גידור החצר קיים במשך שנים רבות. לבקשת התובעת, הנתבעת הקטינה את שטח
החצר המצוי בשימושה, והעבירה חלק ממנה לשימוש התובעת על מנת לאפשר לה
לרדת לחצר ולעשות בה שימוש כרצונה.
התובעת התעלמה ממכתב ב"כ הנתבעת לפיו הנתבעת מוכנה להסיר את הגדר אשר
הוקמה לבקשת התובעת.

15. הבריכה עליה הלינה התובעת הינה ברכה ניידת וזמנית אשר הוסרה עוד בטרם
הגשת כתב התביעה.

16. הנתבעת אפשרה ומאפשרת לתובעת גישה לכל המתקנים הנמצאים בחצר הבית
ואף התקינה על חשבונה שער המאפשר לתובעת גישה חופשית לחצר.

17. אמנם לא בוצע רישום בפועל של הצמדת החצר לדירת הנתבעת. אך התנהגותם
במשך למעלה מ-30 שנה ואומד דעת הצדדים מצביע על הצמדת החצר לדירת
הנתבעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

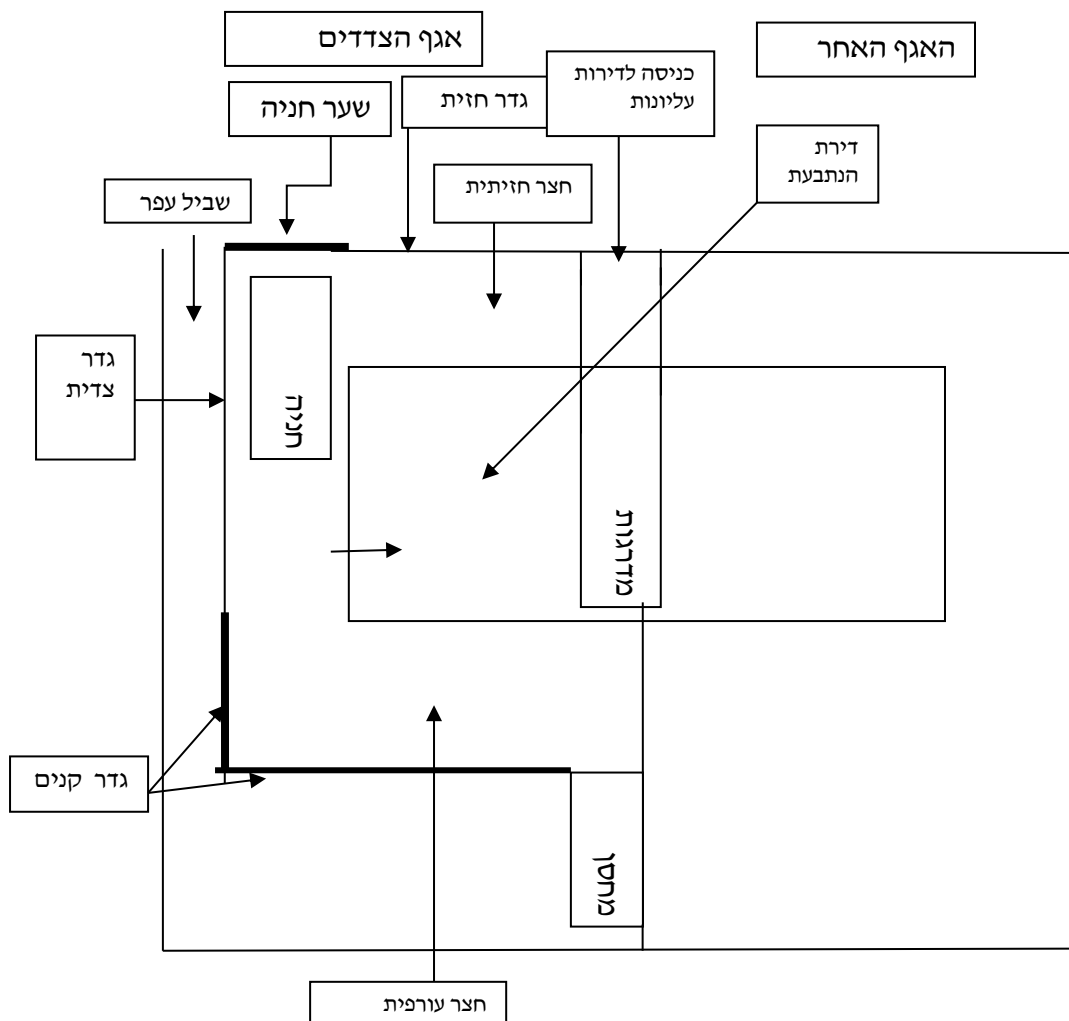
מס' תיק: 4/273/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ד. מהלך הדיון

18. ביום 19.4.15 התקיים קדם משפט.

19. ביום 11.8.15 קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. טרם שאסקור את ממצאי הביקור במקום, ועל מנת להקל על הבנתם, מצאתי למזג בפסק דיני תרשים על גביו יודגמו ויסומנו נתוני הביקור במיקום (משוער) שלא לפי כללי מדידה תקינים. צירוף התרשים נעשה אך לשם הבהרה והמחשת מיקום הנתונים המפורטים.





מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/273/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. להלן הנתונים אותם מצאתי רלוונטיים להליך:

- א. חזית הבית פונה לכיוון הרחוב.
החזית אינה אחידה למראה והיא "מחולקת" למעין 2 מקטעים – אגפים.
אגף אחד - המורכב מדירות הצדדים להליך (להלן: "אגף הצדדים").
אגף שני - המורכב מ- 2 הדירות האחרות שבבית המשותף (להלן: "האגף האחר").
- ב. בין שני האגפים דלעיל ממוקם שביל גישה וכניסה לחדר מדרגות המוביל ל- 2 הדירות העליונות של הבית (ובהן דירת התובעת).
- ג. חזית אגף הצדדים בנויה גדר אבן נמוכה שגובהה כמטר אחד ומעליה גדר עץ שגובהה כמטר נוסף.
- ד. לצד דירת הנתבעת קיים שער רחב וגבוה עשוי עץ עליו תלוי שלט "חניה פרטית" (להלן: "שער החניה"); מאחורי שער זה מצוי אזור חניה מרוצף לכלי רכב.
- ה. בשטח החניה ניצבה מכונית בשימוש הנתבעת או מי מטעמה.
לצד החניה ובהמשכה מצוי שביל כניסה המוביל לדירת הנתבעת ולחצר העורפית.
- ו. בניצב לחזית, במרחק של כ- מטר מגבול החלקה בנויה גדר אבן ומעליה גדר עץ. גדר זו נמשכת עד לחצר העורפית ובהמשכה (גם כן בניצב) קיימת גדר קנים (גדר זו על כל חלקיה תכונה להלן: "גדר צדית").
- ז. בין הגדר הצדית לגבול החלקה קיים שביל עפר.
- ח. בחזית דירת הנתבעת ובעורפה קיימות גינות הנחזות להיות גינות פרטיות לכל דבר ועניין.
- ט. בקצה החצר העורפית ניצב מחסן רחב הבנוי מחומר דמוי איסכורית.
- י. על גבי הקרקע הן בגינה החזיתית והן בגינה העורפית מונח דשא סינתטי ומוצבים מיטלטלין שונים כגון: ספסל, שולחן, כסאות פלסטיק צעצועי ילדים, מתקן נייד לתליית כביסה וכיו"ב.
הגינה העורפית והחזיתית מטופחות למראה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/273/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

יא. בשולי הגינה העורפית קיימת גדר קנים (הניצבת אנכית בצורה המקבילה לחזית הבית) גדר זו מפרידה בין חלקה האחורי של הגינה העורפית לבין יתרת שטח החצר עד גבול החלקה.

יב. חלק החצר האחורי (החלק הכלוא בין גבול החלקה האחורי לבין גדר הקנים) צר יחסית ואינו מטופח כלל. אל חלק זה ניתן להגיע משביל המצוי לצד אגף הצדדים המתואר בסעיף ז' לעיל.

יג. חזית הבית המצויה מול האגף האחר עשויה גדר חיה נמוכה. בקצה הגדר החיה קבוע שער המוביל לשביל צר שבקצהו גינה מטופחת נטועה עצים. באגף האחר לא קיימת חניה.

21. ביום 6.4.16 התקיים דיון הוכחות במהלכו העידו התובעת והנתבעת וכן מר דני מצליח - בנה של בעלת דירה בקומת הקרקע המקבילה לנתבעת ;

22. הצדדים הגישו סיכומי טענות והגיעה העת להכריע בתביעה.

ה. המסגרת הנורמטיבית

23. הלכה היא כי בעל דירה בבית משותף זכאי לעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף אף ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, ובלבד שהשימוש שנעשה ברכוש המשותף הוא שימוש רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן אשר אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ראו ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח (1) 645, בעמוד 648 וכן ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג, פ"ד כח (2) 817,824-825; המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14 - 18, י-ם, פ"ד לה (4) 277 שם נקבע - "כל שימוש מותר גם בלי החלטה של האסיפה הכללית, ובלבד שהוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן ואינו מונע שימוש דומה מאחרים."

24. ס' 62 לחוק המקרקעין קובע: " בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/273/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות" (ההדגשות שלי – ד.ק.ב.).

25. בנוסף, ס' 12 לתקנון המצוי קובע כי: "החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה."

26. משילובם של סעיף 62 לחוק המקרקעין וסעיף 12 לתקנון המצוי עולה, כי לא ניתן להצמיד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה מסוימת ללא הסכמת כל בעלי הדירות (זולת החרוג המפורט בסעיף 71ב' לחוק המקרקעין).

27. תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, אף שלא בוצעה הצמדה במרשם, טעונה הסכמת כל בעלי הדירות שכן, במהותה, דומה פעולת תפיסה החזקה הייחודית לקביעת "הצמדה"; בשני המקרים תגרום הפעולה לגריעה מהזכויות שיש לדיירים האחרים ברכוש המשותף. עמד על כך בית המשפט העליון בע"א 2525/92 ראוברגר נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז (5) 850: "משמעות הדברים היא כי לכל אחד מבעלי הדירות זכות להתנגד לפגיעה ברכוש המשותף על ידי בנייה בו וצירופו לאחת הדירות. "תפיסת חזקה בלעדית על ידי בנייה ברכוש המשותף, המיועד לשמש את כל בעלי הדירות, שוללת לצמיתות את זכות השימוש באותו חלק מהרכוש המשותף משאר בעלי הדירות וברור כי דבר כזה אינו יכול להיעשות אלא בהסכמתם..." (ראו גם רע"א 698/85 בן צור ואח' נ' נעים ששון ואח', פ"ד מא (3) 144; י.ויסמן, דיני קניין בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997) עמ' 455-454).

ראו גם ע"א 136/63, לויניהים נ' שוורצמן פ"ד י"ז 1726 שם נקבע: "... זכות השייכת לכמה שותפים ואינה מתייחסת לעניין שימושי רגיל שכולם נהנים ממנו בדרך של שיגרה, אין אחד השותפים יכול ליטול אותה או חלק ממנה לעצמו ולהדיר את השותפים האחרים ממנה שלא בהסכמתם."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/273/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ובע"א 188/76, רוזנוקס נ' הוטרר, פד"י ל"א (1), 382, בע"מ 384 (להלן: "פרשת רוזנוקס") נקבע: "מעשים של הסגת גבול ברכוש המשותף, היינו מעשים הפוגעים רק באפשרות של שימוש כולו או בחלקו ברכוש המשותף, אמנם זקוקים, כדי שלא יהיו בניגוד לחוק, להסכמה של כל אחד מבעלי הדירות, אך הם אינם מוצאים מידיהם מזכויותיהם החפציות ברכוש המשותף ולכן אין בהסכמה כזאת משום העברתן אל מסיג הגבול. הוא אינו רוכש כל זכות חפצית ברכוש המשותף, אלא כל בעלי הדירות, כבעלים משותפים ברכוש המשותף בכללותו, נשארים בעליו באותה מידה, גם אם הם מסכימים להסגת הגבול".

28. אמנם נקבע בפסיקה כי נטילת חזקה ייחודית ברכוש המשותף טעונה הסכמה של כל בעלי הדירות בבית המשותף, יחד עם זאת, נקבע כי היות ואין בה כדי להקנות למשתמש זכויות קנייניות בשטח אזי אין היא טעונה מסמך בכתב, (ראו פרשת רוזנוקס לעיל): "אין בהסכמה הנ"ל, המרשה לאחד מבעלי הדירות להשתמש במידה מסוימת ברכוש המשותף לצרכיו הפרטיים, משום הקניית זכות במקרקעין... ולכן היא אינה טעונה רישום... והיא אינה טעונה מסמך בכתב לפי סעיף 8 לחוק". על הלכה זו חזר בהמ"ש העליון גם בע"א 815/81, כליפא נ' שאול פ"ד ל"ו (3) 78, בעמ' 83.

29. כאמור, בכל הנוגע להסכמה שעניינה רשות לשימוש במקרקעין, ניתן ללמוד עליה אף מכללא, וכן מהתנהלות הצדדים במשך השנים (ראו ע"א 32/77 טובוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד לא (3) 201 שם נקבע כי "לשם יצירת רשיון של שימוש במקרקעין אין צורך בהסכם מפורש ומספיקה התנהגותם של בעלי מקרקעין שממנה ניתן להסיק שהסכימו בדיעבד והשלימו עם שימושם של אדם אחר ברכושם. העובדה שעבר זמן רב מאז תפס אדם את הקרקע ושבמשך כל אותו זמן נמנע בעל הנכס מתגובה כלשהי, למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו וליצור רישיון מכללא" (ראו גם: ע"א (מחוזי י-ם) 9502/06 לומברוזו נ' קובנר (פס"ד מיום 7.8.07 - פורסם באתרים משפטיים).

30. רישיון מכללא הוא רישיון הניתן לביטול בכל עת. עם זאת, נקבע כי במקרים מיוחדים שבהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מהסכמה, ומקום שבהסתמך על מתן הרישיון השקיעו בעלי הרישיון כספים רבים במקרקעין, תוענק לבעלי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/273/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הרישיון הגנה על ציפיתם הלגיטימית (ראו : ע"א 32/77 הנ"ל; ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד, פ"ד נח (4), 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס, פ"ד מט (2) 419; ע"א 2836/90 בצר נ' צילביץ, פ"מ מו (5), 184; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן, פ"מ לא (2) 127; ע"מ 6343/12 פלונית נ' פלונית (פס"ד מיום 8.11.12 - פורסם באתרים משפטיים).

31. "רישיון חינוס", בוודאי מקום בו הוא נלמד מכללא, מהווה זכות אישית, הניתנת לביטול עם גילוי דעתו של המקנה שאין ברצונו להמשיך בהענקת הרישיון: "רשות שנלמדת מכללא אינה מונעת את בעל המקרקעין מלהביא לסיומה בכל עת על ידי גילוי דעתו כלפי פלוני שאין הוא מוכן עוד להמשיכה. זו היא רשות חינוס המתחדשת מרגע לרגע, כל עוד לא פעל בעל המקרקעין לסילוקו של פלוני". ראו פרופ' נ. זלצמן, רישיון במקרקעין, הפרקליט מב, 24, 57; וראו גם מ. דויטש, קניין כרך ב' (התשנ"ט-1999) 414.

1. דיון והכרעה

32. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה (למעט ביחס לגדר שבחזית אגף הצדדים). להלן נימוקי הכרעתי :

האם חצר הבית הוצמדה לדירת הנתבעת ?

33. חצר הבית, גם אם היא סמוכה באופן פיזי לדירת הנתבעת, לא הוצמדה (משפטית) לדירת הנתבעת. לא הוכח בפני קיומו של הסכם בכתב בין בעלי הדירות בדבר הצמדת חצר או חניה לדירתה.

שימוש ייחודי

החצר החניה והמחסן

34. מביקורי במקום שוכנעתי כי הן החצר החזיתית והן החצר העורפית נחזות להיות פרטיות; הדברים דלעיל נכונים אף ביחס לחניה ולמחסן. הנתבעת עצמה מודה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/273/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעדותה הראשית כי היא עושה שימוש ייחודי בחצר הבית ובחניה אלא שלטענתה, שימוש ייחודי זה התקיים משך שנים ארוכות בהרשאת התובעת.

35. אכן, בעת ביקורי במקום הבחנתי כי הגדר הצדית שהוקמה היא גדר "ותיקה" אשר יצרה למעשה "חצר בתוך חצר". גדר הקנים אשר בחצר העורפית היא גדר חדשה (יחסית) אשר הוקמה על ידי הנתבעת במטרה להפיס את דעתה של התובעת (ראו סעיף 32 לתצהיר עדותה הראשית של הנתבעת). על פי עדות הנתבעת עובר להקמת גדר הקנים כל השטח שבעורף הבית היה מגודר ובשימושה הייחודי של הנתבעת. ביחס לחזית הבית- אזי קיומו של שער החניה (ולא קיומה של גדר חזית אגף הצדדים) הוא אשר יוצר תחושה ונראות של חזקה ייחודית הן בחניה והן בחצר החזיתית שכן הוא תוחם חלקים אלו ומנכס אותם לדירת הנתבעת.

36. השימוש דלעיל אשר נעשה על ידי הנתבעת אינו מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף על פי המבחנים שנקבעו בפסיקה. אין ספק שהשימוש אשר מבצעת הנתבעת בחצר מונע מהתובעת עשיית שימוש דומה ברכוש המשותף, ומשכך, אין שימוש זה יכול להוות "שימוש סביר".

37. לא מצאתי כי בנסיבות תיק זה קיימת חלוקת שימוש רבת שנים בין הצדדים או כי קיים "ויתור הדדי" כלשהו בין כל בעלי דירות בבית. מהביקור במקום התרשמתי שבעוד שבעלי הדירות בקומות הקרקע נהנים משימוש ייחודי בקרקע בעלי הדירות בקומות העליונות לא נהנים משימוש ייחודי כלשהו אחר. גג הבית נותר רכוש משותף (ראו גם עדותו של מר דני מצליח עמ' 15 לפרוטוקול ש' 4-3).

38. כאמור, פעולות הנתבעת (או מי מטעמה) מהוות שימוש ייחודי ברכוש המשותף אשר אינו עולה בקנה אחד עם מבחני השימוש הסביר כפי שנקבעו בפסיקה שנזכרה לעיל.

"כשהם באו לא היתה חניה, לא היה שער לא לחניה ולא לבית. הכול היה פתוח, בצד אחד היה בלוקים ובצד אחד היתה דלת רגילה" (עמ' 4 לפרוטוקול ש' 25-24).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/273/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

השימוש שנעשה עולה כדי "הצמדה בפועל" והוא מחייב את קבלת הסכמתם של כל בעלי הדירות ובכלל זאת הסכמת התובעת. אציין כי מעדות התובעת הנ"ל עולה כי גדר הבית החזיתית (גדר הבלוקים שכיום מעליה גדר עץ) היתה קיימת עוד בראשית הבית. גדר העץ המגביהה התווספה לגדר הנ"ל רק בהמשך.

האם הסכימו כל בעלי הדירות לשימוש הייחודי הנעשה על ידי הנתבעת

39. התובעת העידה כי רכשה את דירתה לפני 57 שנים ואילו הנתבעת ובעלה ז"ל רכשו את דירתם לפני כ- 30 שנה.

40. התובעת מאשרת בעדותה כי בסמוך למועד כניסתם לבית המשותף בנו הנתבעים חניה פרטית משלהם בתוך הרכוש המשותף (ראו סעיף 7 לתצהיר עדותה הראשית של התובעת). בנוסף, בנו הנתבעים מחסן בתוך הרכוש המשותף. התובעת אינה מכחישה כי לא נקטה פעולות יזומות לשינוי המצב וזאת מאחר והיא "לא התפנתה לטפל בענייני הבית" מחמת מחלת בעלה (עמ' 3 לפרוטוקול שורות 19-21).

41. התובעת העידה כי החניה והמחסן נבנו ללא רשותה ("זה נבנה ללא רשותי. אף אחד לא שאל אותי..." (ראו עדות התובעת בעמ' 4 לפרוטוקול שורות 29-30).

42. מעדותו של מר דני מצליח (בנה של בעלת הדירה המקבילה לדירת הנתבעת בקומת הקרקע) - אשר היתה מהימנה בעיני - שוכנעתי כי חלוקת החצר לשניים והקצאת השימוש בחצר לדירות הקרקע לא היתה תולדה של "הסכם" אלא מדובר בחלוקה בנסיבות שבהן "איש אף פעם לא התלונן" (ראו עמ' 13 שורות 10-13).

43. הנתבעת לא הוכיחה כי קיבלה הסכמה פוזיטיבית בין בכתב בין בע"פ לשימוש המבוצע על ידה. לא הוכחה הסכמה של ממש בראיות כלשהן (ראו עמ' 7 לפרוטוקול ש' 3,6,9 עמ' 14 ש' 4-5 ועמ' 13 ש' 18-24).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/273/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

עם זאת, שוכנעתי כי במשך שנים הסכימה התובעת, למצער לחלק מן השימושים שנעשו ע"י הנתבעת ברכוש המשותף. הסכמה זו לא באה לידי ביטוי בכתב, אלא בשתיקתה של התובעת נוכח פעולות הנתבעת ביחס לרכוש משותף במרוצת השנים והשימוש שנעשה בו על ידי הנתבעת או מי מטעמה. לאור האמור עסקינן ברישיון מכללא.

44. ההלכות שצוטטו לעיל ביחס ל"רישיון במקרקעין" תקפות גם ביחס למתן רישיון לשימוש ייחודי ברכוש המשותף של בית משותף. בהקשר לכך, ובהתחשב בטיב היחסים שבין בעלי הזכויות בבית משותף, מן הראוי להקפיד על שמירת זכויותיהם הקנייניות של בעלי הדירות ולהישמר לבל תתפרש שתיקתו של בעל דירה כהסכמה ממנה לא ניתן יהיה לחזור.

יפים לעניין זה דברי בית המשפט המחוזי בע"א (מחוזי ת"א) 271/85 הילמן נ' רוזן (פורסם באתרים משפטיים) ובר"ע 107/86 עזבון המנוח אברהם רימר נ' הילמן (פורסם באתרים משפטיים), שם נקבע כי: "מקובל שדיירי הקומות העליונות בבתי משותפים נמנעים מלאכוף בפועל את זכותם הקניינית בחצר הבית ומתירים לדיירי קומת הקרקע להשתמש בשטח הצמוד לדירתם בין בדרך של הקמת גינה או לצרכי ישיבה ושהייה וכיוצא בזה. אולם, לדעתי אין להסיק מהתנהגות כזו מסקנות של הבטחה או ויתור על זכויותיהם. אם ננהג בדרך זו נאלץ את בעלי הדירות הגבוהות להפגין התנגדות ואי שביעות רצון, כדי למנוע בעתיד טענות של מניעות ע"י התנהגות או הבטחה". (ר' גם ח. דגן קניין על פרשת דרכים, 395).

45. באופן דומה נפסק גם בת"א (מחוזי- ת"א) 2816/03 קונצי'צקי נ' שפלן (פורסם באתרים משפטיים) כי: "בהסקת מסקנות בדיעבד בדבר אישור השימוש הייחודי בגג הבית המשותף יש משום הגמשה של כללי ניהול הבית המשותף, שלילת הוודאות ומתן אפשרות ליצירת זכויות על ידי קביעת עובדות בשטח. אישור שכזה מנוגד לתכלית הראויה... ואולם, גם בהנחה המיטיבה עם המשיבים ששתיקת המערערים במשך השנים מהווה מתן הרשאה לשימוש הייחודי שאותו עשו בגג הבית, הרי לכל היותר אפשר לראות את השימוש כנעשה בגדר הדוקטרינה של "רישיון במקרקעין" ללא תמורה. כפי שנפסק לא אחת,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/273/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרשאת חינם שכזו ניתנת לביטול עם גילוי דעתו של המקנה שאין ברצונו להמשיך בהענקת הרשיון... לא שוכנענו כי במקרה דנן מתקיימות נסיבות שניתן ללמוד מהן על רשות בלתי הדירה. על פי ההלכה הפסוקה, רק במקרים נדירים שבהם הוענקה לבעלי הרשיון גם הרשות לבנות ובהסתמך על מתן רישיון לצמיתות השקיעו בעלי הרישיון במקרקעין, הכירו בתי המשפט בטענה בדבר אי הדירותה של הרשות...".

46. שוכנעתי, איפוא, כי התובעת הסכימה מכללא, או למצער לא מחתה באופן גלוי ומפורש, כנגד השימוש הייחודי של הנתבעת בחלק מהרכוש המשותף של הבית וזאת על אף שהמצב הפיזי של החצר והחניה היה גלוי לעיניה (ראו עמ' 3 לפרוטוקול שורות 24-25).

האם רשאית התובעת לחזור בה מהרשאתה

47. מקום שמדובר ברשות חינם לעשיית שימוש ייחודי ברכוש המשותף - ושוכנעתי כי זהו המצב בעניינו - (ראו עדות הנתבעת בעמ' 7 לפרוטוקול ש' 21 לפיה: "**ההסכם לא כלל תמורה**") אזי מדובר ברשות הדירה. משכך, עלי להוסיף ולבחון האם רשאית התובעת לבטל את ההרשאה שניתנה, ואם כן, באילו נסיבות.

48. ככלל, רשות חינם ניתנת לביטול בכל עת עם גילוי דעתו של נותן ההרשאה על סיומה; אין ספק שבעצם הגשת התביעה גילתה התובעת את דעתה כי הרשות שניתנה על ידה - באה אל קיצה.

האם קיימות נסיבות המצדיקות שלא לאפשר לתובעת לחזור בה מהרשאתה

49. ניכר כי הנתבעת השקיעה במרוצת השנים ממון לצורך טיפוח חצר הבית, הקמת החניה והמחסן וזאת מבלי שהתובעת השתתפה בהוצאות אלו. עם זאת, שוכנעתי כי לצד השקעתה בנכסים אלו היא גם נהנתה מתמורה בדמות שימוש ייחודי בהם במהלך אותן השנים ללא כל הפרעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/273/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

50. הפסיקה הכירה במקרים מסוימים בהם רשות שניתנה ללא תמורה נחשבה כרשות בלתי הדירה וזאת כאשר עקרונות הצדק ותום הלב דורשים זאת וכאשר ברור כי הנסיבות יצרו הסתמכות צפויה הגיונית ולגיטימית של מקבל הרשות לפיה הרשות שניתנה היא לצמיתות (ראו עמ"ש (מחוזי מרכז) 37005-01-14 **פלוני נ' פלוני** פסק דין מיום 30.12.14 פורסם בנבו והאזכורים המופיעים בו).

51. לא שוכנעתי כי נסיבות תיק זה מצדיקות ציפייה סבירה ולגיטימית מצד הנתבעת כי מדובר ברשות בלתי הדירה לצמיתות.

ראשית, לא הוכחה הסכמה פוזיטיבית או כתובה מאת בעלי הדירות אלא הסכמה מכללא בלבד. אמנם, עצם חלוף הזמן (30 שנה) יכול ויצר אצל הנתבעת ציפייה להמשך הרישיון, ברם, בהתחשב בטיב הרישיון ונסיבות יצירתו – אין די בכך. הנתבעת מאשרת כי לא הוצג בפניה כל מסמך המאשר ההסכמה (עמ' 11 לפרוטוקול שורה 3). עדותה היתה כי : **"נאמר לי שיש הסכם ביחס לקרקע. הסתכלתי על השטח של הדיירת הצמודה אלי וראיתי שכל השטח מסביב הוא שלה והיא מטפלת בו, בגלל זה קניתי את הבית"** (עמ' 6 לפרוטוקול שורות 25-26). ברי כי רכישת חצר וחניה היא בעלת ערך כלכלי; זכות שכזו להצמדת החצר או חניה אמורה היתה להיות מעוגנת בהסכם המכר שנחתם בין הנתבעת לבין בעלי הדירה (קודמיה) אשר מכרו לה את דירתם. ברם, אף התובעת אשרה בעדותה כי ההסכמה עליה נסמכה אינה מופיעה בהסכם המכר (עמ' 6 שורות 24-25).

למותר לציין כי מוכרי דירת הנתבעת לא הובאו כלל על ידה לעדות לשם אימות גרסתה ביחס למהות ההסכמה והיקפה.

כלל ידוע הוא כי צד להליך שנמנע מהבאת עד או ראיה רלוונטית ייחשב הדבר כראייה נגדו. הלכה זו נטועה בניסיון החיים ובשכל הישר. צד הרוצה לשכנע בטענותיו, וישנן ראיות העשויות לסייע לו בכך, עליו לדאוג להבאתן. משלא עשה כן, פועל הדבר לחובת גרסתו.

גם העד מצליח, שעדותו מהימנה עליי, שלל את גרסת ההסכם שהתגבש (ראו עדותו בעמ' 13 שורות 18-24).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/273/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

האם יש נסיבות המצדיקות הותרת המחסן

52. הקמת מחסן ברכוש המשותף עשויה להיחשב כ"הרחבת דירה" במובן סעיף 71 לחוק המקרקעין התשכ"ט 1969, ככל שהמחסן מהווה המשך טבעי ופיזי לדירה המורחבת (ראו : רע"א 1462/10 עטייה נ' שגיא (פורסם באתרים משפטיים)). מקום שמדובר ב"הרחבת דירה" תידרש הסכמת 3/4 מבעלי הדירות אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירתם. ואולם, המחסן מושא ההליך אינו מצוי בסמיכות פיזית למבנה, אלא מצוי בעורף החלקה ללא קשר פיזי כלשהו לדירת הנתבעת ומשכך, הוא אינו מהווה "הרחבת דירה". לאור זאת, אף הקמתו טעונה הסכמתם של כל בעלי הדירות בבית. ברם, הסכמות כאמור לא הוכחו בפניי בעדויות.

53. לא מצאתי כי עקרונות צדק ותום לב מצדיקים הימנעות מסיומה של הרשות בנסיבות העניין.

ז. סיכום

54. לנוכח כל האמור לעיל, אני מורה בזאת לנתבעת להסיר את שער החניה, הגדר הצדית, גדרות הקנים והמחסן.

האמור לעיל ייעשה בתוך 90 יום מהיום.

55. בהינתן שיוסרו הגדרות הנ"ל לא מצאתי, לאור נימוקיי בסעי' 35 לעיל, להורות על הסרת הגדר שבחזית אגף הצדדים (גבול החלקה). ככל שבעלי הדירות מעוניינים ליצור חזית אחידה לבית יהיה עליהם לקיים אסיפה כללית שתכריע בכך.

56. חצר הבית מהווה רכוש משותף של כל בעלי הדירות בבית אשר רשאים לעשות בה שימוש סביר ולא קיימת זכות שימוש ייחודי בה לנתבעת בלבד.

לאור האמור אני מורה לנתבעת לסלק מהחצרות את כל המיטלטלין אשר הניחה בהן בתוך 90 מהיום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/273/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

57. יוטעם, כל בעל דירה בבית רשאי להוציא אל חצר הבית מיטלטלין דוגמת שולחן וכיסאות לצורך עשיית שימוש בחצר ובלבד שהמיטלטלין הנ"ל ייאספו כל יום חזרה אל הדירה עם סיום השימוש בחצר וכי השימוש ייעשה בתום לב ובהתחשב בנתוני הדירות.

58. אני מחייבת את הנתבעת בהוצאות התובעת בהליך הכוללות שכ"ט עו"ד בסך כולל של 5,000 ₪ אשר ישולמו עד ליום 1.3.17.

59. סכום אשר לא ישולם במועד יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום שנועד לתשלום ועד מועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום ל' שבט תשע"ז (26 פברואר 2017) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.

דגנית קציר – ברין
מפקחת על רישום מקרקעין
חולון